

1500049-34.2021.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500049-34.2021.8.26.0550 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500049-34.2021.8.26.0550 - 2021/000032

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL GIOVANI DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

GABRIEL GIOVANI DOS SANTOS, qualificado foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 18:56 horas, na Rua 5, defronte ao nº 172, Jardim Araucária, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 78 (setenta e oito) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 20,7 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 16/18 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 71/73, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 15 de julho de 2021.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, restando prejudicado o interrogatório do acusado, em face da revelia.

Em alegações finais, o ilustre Representante do Ministério Público, à vista da

prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e fixação de regime prisional aberto, em caso de reconversão, impondo-se, ainda, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida porque decorrente da atividade ilícita.

Já a ilustre Defensora Pública, dizendo insuficiente a prova produzida no que diz com a totalidade do entorpecente apreendido, não se evidenciando, ademais, a atividade mercantil, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação pela imputação inicial, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto, facultando-se, por fim, a interposição de eventual recurso em liberdade, promovendo-se a restituição dos valores apreendidos.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 71/73, com resultado positivo para cocaína.

Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Conquanto somente na fase inquisitória -- em juízo fez-se revel --, o acusado afirmou que estava no local onde abordado tão somente para cobrar vinte reais de um adolescente que estava por lá vendendo entorpecentes, negando que lhe pertencesse toda a droga apreendida, como também que estivesse realizando o comércio ilícito, dizendo-se usuário (fls. 4).

Todavia, a versão deduzida pelo acusado, foi contrariada pela prova produzida. De fato, os Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, reiterando o que inicialmente exposto, disseram que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido ponto de venda de entorpecente, quando avistaram o acusado mantendo contato com um motociclista, com quem trocava alguma coisa, por isto que se aproximaram e o abordaram, tendo antes o condutor da motocicleta se afastado rapidamente do local, impossibilitando fosse igualmente abordado. Com o acusado, em suas mãos, foram apreendidas quatorze porções de cocaína, estando outras sessenta e quatro porções da mesma substância entorpecente sob as vestes dele, acompanhadas da quantia de trinta reais, admitindo, então, que estava no local realizando o comércio ilícito.

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829). Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser

sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Deste modo, as circunstâncias indicadas não apenas revelam a posse do entorpecente mas também a sua destinação mercantil, seja porque se tratava de local já conhecido pela realização do comércio ilícito, seja pela movimentação do acusado, mantendo contato com um motociclista, com quem trocou alguma coisa, seja, por fim, em razão da quantidade de porções de cocaína apreendida em poder dele, parte da mesma sob suas vestes, acompanhada de certa quantia em dinheiro, que disse decorrente da atividade ilícita.

Assim, todos esses elementos probatórios reunidos permitem seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial, incidindo sobre a quantia em dinheiro apreendida, porque decorrente do tráfico, a pena de perdimento.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, possível seja fixada a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de considerar as circunstância atenuante da menoridade, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Por fim, deve a pena-base cominada ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito. O acusado é primário, não ostenta condenação criminal anterior, não havendo indicação suficiente, por ocasião dos fatos, de que estivesse já dedicado à atividade criminosa, de tal modo que, também em função da pouca quantidade de entorpecente, deve a pena base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que

a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado GABRIEL GIOVANI DOS SANTOS à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA